

1500855-68.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... pandêmico", com a valoração do "tráfico privilegiado", fixando-se regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição/apreensão (fls. 20), laudo de constatação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500855-68.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-68.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214938/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 13307015 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10913/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2214938 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FELIPE BOMBONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Diego Felipe Bombonato, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 31 de agosto de 2020, às 20h30min, na Avenida Rodrigues Alves, número 3-22, no bairro Jardim Redentor, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 23 pedras de 'crack', para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição/apreensão (fls. 20), laudo de

constatação preliminar (fls. 22/25) e laudo definitivo (fls. 80/83).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 62/66), foi concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 90/92, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 107), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 111).

Na decisão de fls. 117/118, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 140/142 as partes desistiram da oitiva da testemunha Guilherme Rodrigues Rosa Cardoso, pleito homologado. Ainda no mesmo ato processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 150/158 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a constatação da agravante do "estado pandêmico", o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a D. Defesa, às fls. 162/171 pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, fixando-se a pena-base no mínimo legal, afastando-se a agravante do "estado pandêmico", com a valoração do "tráfico privilegiado", fixando-se regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição/apreensão (fls. 20), laudo de constatação preliminar (fls. 22/25) e laudo definitivo (fls. 80/83).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Marcelo Wanderlei Barreira e Rodrigo Fabiano Ortiz, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que receberam 'informações anônimas' de que uma pessoa chamada Diego, vestindo calça moletom cinza e camiseta branca de time de futebol, estaria em um bar comercializando "crack". Afirmaram que foram ao local e encontraram o acusado, sendo que, ao notar a aproximação dos policiais, ele correu para o banheiro. Informaram que conseguiram segurar a porta do banheiro e notaram (mais precisamente o policial Marcelo) quando o réu dispensou ao solo, atrás do vaso sanitário, uma latinha contendo 23 pedras de crack. Esclareceram que, na posse dele, ainda havia 185 reais em cédulas diversas. Mencionaram que Guilherme, também abordado, disse que era usuário e estava no local para comprar droga do réu. Citaram que, posteriormente aos fatos, o acusado voltou a ser preso, no mesmo local, por tráfico.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Diego Felipe Bombonato sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do tráfico de drogas. Disse que estava no banheiro masculino do bar e, quando de lá, saiu, viu um policial segurando Guilherme. Afirmou que o policial entrou no banheiro e encontrou as drogas. Informou que não conhecia Guilherme e, por isso, nunca vendeu droga para ele. Esclareceu que tem vários "moleques" vendendo drogas naquele bar.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais receberam "denúncia anônima" corresponde com as características do local.

Já no bar, o acusado correu (comportamento atípico para um mero usuário), sendo apreendido, com ele, dinheiro, em notas miúdas, sem comprovação lícita.

Portanto, há prova de que o acusado lá realizava o comércio espúrio, o que espanca a possibilidade de desclassificação para o delito de consumo.

Aliás, tempos depois (já que o acusado foi beneficiado com liberdade provisória), foi ele novamente surpreendido por policiais, no mesmo bar, mais uma vez realizado o comércio espúrio.

Tanto é assim, que à época da triangulação da relação jurídica-processual foi ele já citado no estabelecimento prisional (fls. 107).

Portanto, nos moldes do art. 28, §2º da Lei Antidrogas, inviável a desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, até porque, como visto, a prova testemunhal é segura.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A coletividade (saúde pública) foi maculada nos estritos termos do tipo legal.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e

quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Ocorre que ante a natureza permanente do tráfico, o próprio delito pode servir de fundamento para demonstrar a ocorrência da atividade criminosa.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE

CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal no ponto em que a pena-base da paciente foi elevada em apenas 10 meses de reclusão, ante a grande quantidade de substância entorpecente apreendida (1.465 g de cocaína) e de sua natureza, de elevado efeito nocivo à saúde, em observância ao disposto no art. 42

da Lei n. 11.343/2006. 2. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é exigido do acusado que seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. 3. Não obstante a paciente seja primária, a instância antecedente concluiu que ela não era uma traficante eventual, com fundamento em seu histórico de viagens e suas declarações sobre o motivo de deslocamento aéreo anterior ao Brasil, tudo a evidenciar que se realizou transporte internacional de entorpecentes em oportunidade pretérita. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 318558 SP 2015/0053054-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015)(grifo meu)

No caso concreto, o acusado efetivamente vendia os entorpecentes (ato de mercancia), o que denota que já desenvolvia atividades criminosas há algum tempo. Por isso, a pena atingida na primeira fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

Isto porque, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta maneira, CONDENO o acusado DIEGO FELIPE BOMBONATO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu a este processo solto e assim poderá recorrer.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA